

1516427-61.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... HABEAS CORPUS. DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com relação ao tráfico privilegiado, não foram apontados fundamentos idôneos para deixar de reconhecer a sua aplicação ao caso dos autos. Acórdão impugnado baseado apenas em mera presunção de dedicação ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516427-61.2021.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1516427-61.2021.8.26.0228

Controle nº 788/21

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

KAIANE FERNANDA DA SILVA

Aos 25/08/22, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, a ré KAIANE FERNANDA DA SILVA e a sua defensora, Dra. Maria Joyce dos Santos Silva - OAB/SP 431924. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. A ré foi interrogada. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: A ação é procedente, uma vez que os fatos narrados na inicial restaram bem comprovados diante das provas produzidas nos autos. De fato, os policiais ouvidos nesta data afirmaram que haviam recebido denúncia anônima referente a tráfico de drogas no local, tendo sido informado que uma mulher, com determinadas características e vestimentas, realizava a traficância. Diligenciaram ao local dos indicado a fim de averiguar a procedência da denúncia e no interior da viela, visualizaram uma mulher com as características e roupas fornecidas na denúncia. Abordaram a ré e com ela encontraram uma mochila, dentro da qual estavam os entorpecentes apreendidos, todos embalados individualmente para a venda, bem como valor em dinheiro. Conversando com a acusada, esta admitiu estar comercializando entorpecentes naquele local, quando então lhe foi dada voz de prisão. Ao ser interrogada tanto na fase policial quanto em Juízo, a ré confessou a prática do delito, afirmando que estava passando por dificuldades. O laudo

toxicológico juntado aos autos comprovou a materialidade do delito. Desta forma, comprovadas que foram autoria e materialidade, requeiro que KAIANE FERNANDA DA SILVA seja CONDENADA nos termos da denúncia, aplicando-se pena base no mínimo legal, dada sua primariedade, fixando-se o regime semi aberto para início de seu cumprimento. Pela defesa foi alegado, em síntese: Kaiane Fernanda da Silva foi denunciada por ter supostamente praticado o delito previsto no Artigo 33 da Lei de Drogas. Ocorre que no dia 07 de julho de 2021 a ré foi flagrada portando uma mochila contendo variadas substâncias ilícitas. A ré teria confessado a prática delitiva informalmente e em solo policial alegando que aquela era uma atitude desesperada pois estava desempregada à época dos fatos e sem conseguir suprir suas necessidades básicas, relatou também que se arrepende do feito. Em sede de audiência de instrução e julgamento reiterou o depoimento apresentado quando da prisão em flagrante. A ré é primária e de bons antecedentes. Ainda, os autos demonstram que não é dedicada a atividades criminosas e vem resgatando sua prisão domiciliar há mais de um ano sem nenhuma violação. Por tais motivos a ré faz jus à aplicação da diminuição de pena prevista no §4 do artigo pelo qual é denunciada, não havendo qualquer óbice para tal; A quantidade de substâncias apreendidas não pode ser usada para afastar a diminuição requerida, conforme entendimento do STJ: AGRADO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com relação ao tráfico privilegiado, não foram apontados fundamentos idôneos para deixar de reconhecer a sua aplicação ao caso dos autos. Acórdão impugnado baseado apenas em mera presunção de dedicação ao tráfico, não apontando elemento concreto para comprovar a habitualidade ou a dedicação a atividades criminosas. 2. A jurisprudência desta Corte está consolidada na linha de que a quantidade de drogas, por si só, não constitui fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.243/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) Não ficou comprovado também que havia habitualidade ou dedicação a atividades criminosas pela ré, pois ela, ao ser interrogada, confessou que aquele era o seu quinto dia no comércio dos entorpecentes e que só o fez por desespero e desemprego, o que na atual conjuntura do país é uma justificativa plausível, ainda que não seja nada louvável. Mas a confissão da ré, nos moldes em que ocorreu, denota a personalidade de um agente inábil no mundo do crime, quase que inocente, e por isso deve ser recompensada, já que desde o início procurou colaborar com a justiça. O fato de decidir permanecer em silêncio em audiência não pode ser considerado para piorar sua pena, ou para que se deixe de aplicar a redutora em seu patamar máximo, não havendo nenhuma circunstância agravante no processo é de rigor a diminuição da pena em 2/3. O Ministério Público sustenta a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, "j" do CP sem indicar, contudo, o nexo causal entre a conduta praticada e a calamidade pública provocada pelo Coronavírus. Dessa forma, o pedido para agravar a pena não merece ser deferido conforme entendimento jurisprudencial consolidado, em respeito ao Princípio da Individualização da Pena. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. 1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito. 3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente. 4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos

fundamentos declinados. (HC 654.255/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 07/06/2021) Dessa forma, a defesa de Kaiane Fernanda da Silva requer: 1 - Aplicação da pena no seu mínimo legal; 2 - Aplicação da atenuante da confissão, ainda que parcial; 3 - Não aplicação da agravante prevista no Artigo 61, II, "j" considerando a inexistência de nexos causal da conduta e a calamidade pública; 4 - Diminuição prevista no §4 do Artigo 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo, qual seja 2/3. 5 - Fixação de regime inicial ABERTO, ou, alternativamente, reconhecimento do tempo de prisão domiciliar cumprida para fixação de regime menos gravoso; e 6 - no caso de condenação em regime gravoso, possibilidade de recorrer em liberdade. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. KAIANE FERNANDA DA SILVA, qualificada nos autos, está sendo processada porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, drogas, consistentes em 53 invólucros contendo o total de 207,3g (duzentos e sete gramas e três decigramas) de maconha (Tetrahydrocannabinol), 02 frascos acondicionando 18ml (dezoito mililitros) de Tricloroetileno, substância popularmente conhecida como "lança-perfume", 45 invólucros contendo 5,5g (cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína na forma de crack, e 148 invólucros acondicionando 70,6g (setenta gramas e seis decigramas) de cocaína, todas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A ré foi presa em flagrante, sendo após livrada solta. Notificada, houve defesa preliminar, devidamente apreciada. Recebida a denúncia, foi a ré citada e na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. A ré foi então interrogada. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação da imputada, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu as teses e os benefícios requeridos nesse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade do delito de tráfico de drogas restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo químico-toxicológico positivo para cocaína, maconha e tricoloroetileno, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que a substância entorpecente era trazida pela ré, para fins de comércio. Em seu interrogatório judicial, confessou o narcotráfico, dizendo que era a primeira vez que fazia, arrependendo-se. A denúncia procede. As testemunhas arroladas na denúncia, em uníssono, ouvidas em juízo, relataram que souberam de denúncia de mulher traficando drogas no local. Viram a ré, que convergia com as características passadas, e ao lado dela havia a mochila com os quatro tipos de droga, tendo a ré confessado a narcotraficância. A condenação é de rigor, diante do conjunto probatório suficiente, a indicar que a ré trazia drogas para o comércio ilícito. As testemunhas ouvidas, outrossim, não são suspeitas, mormente apenas por serem agentes da segurança pública. Nada há que as impeça de depor e de se crer em suas palavras, ainda mais quando roboradas pelo restante do conjunto de provas. Além da firme prova testemunhal, a ré confessou em juízo a autoria do delito, tendo sido encontrada com as drogas. A redução da sanção, indicada no § 4º, do artigo 33 da lei nº 11.343/06, que dispõe que as penas referentes a este artigo poderão sofrer redução de um sexto a dois terços, caso seja o agente primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser aplicada, posto ser o caso da ora imputada. A redução deve se dar no patamar próximo do máximo de lei, pois a quantidade de drogas é de razoável a pequena, longe de ser efetivamente grande, sendo a redução de três quintos. Na fixação da pena do tráfico de drogas, atento às circunstâncias do caso em tela, e ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, deve a sanção ser fixada no mínimo legal, perfazendo pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Na segunda fase de fixação de sanção, deveria a pena ser aumentada de três meses em virtude do crime praticado em pleno período de declaração de calamidade pública, bastando sua aplicação, pela letra da lei, que a prática delitiva ocorra nesse período, o que já indica grande desvalor da conduta, além de estar intrínseco o

aproveitamento dessa situação para o cometimento da infração penal, desnecessitando outras demonstrações probatórias. Ocorre que compenso o aumento com a atenuante da confissão, restando a pena inalterada. Por fim, reduzo a sanção do patamar já indicado, em razão da primariedade, com pena final de dois anos de reclusão e duzentos dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, a ré KAIANE FERNANDA DA SILVA, qualificada nos autos, dando-a como incurso no artigo 33, §4º, da lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a cumprir a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa no valor unitário mínimo legal. Diante do cancelamento da súmula 512 pelo E. STJ, em consonância com decisão plenária do E. STF, que julgou ausente o caráter de hediondez do delito do tráfico chamado privilegiado, quando o §4º do artigo 33 é aplicado, resta no caso presente afastado o caráter de hediondez do delito. Outrossim, em cumprimento à decisão em HC (596.603-SP), com abrangência de coletivo, proferida pelo E. STJ, vedada a imposição de regime fechado (ainda que inicial) a casos como o presente, de tráfico privilegiado, em que se aplicou o §4º do artigo 33, da Lei Antidrogas, e dessa forma afastado eventual entendimento do juízo por regime prisional inicial mais severo, imponho o regime aberto para o início do cumprimento de pena, desde logo, mais uma vez atento ao referido HC coletivo, eis que em tal r. decisão consta a determinação de imposição de regime aberto em casos como o presente, em que a pena mínima ou próxima da mínima, com a redução máxima ou próxima da máxima, foi imposta. Por tal motivo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária que fixo em um salário mínimo, dirigido a instituição com destinação social, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais. Poderá apelar em liberdade. Autorizo a incineração da droga, se já não feita. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes e a ré por intimadas. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada Mais. Eu, André Paiva Macedo, escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES

Certifico e dou fé que as partes saíram intimadas da r. Sentença. Eu, André Paiva Macedo, escrevente.